

1500173-25.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/3 NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500173-25.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500173-25.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FABIO BIZINELE FELIPE DA SILVA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

FABIO BIZINELE FELIPE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, em ocasião de calamidade pública, agindo previamente acordado e com unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si um aparelho celular de marca Motorola, modelo G 7 Plus, pertencente à vítima J.X.J.F.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Em audiência, foram ouvidas a vítima e uma das testemunhas arroladas na denúncia, sendo homologada a desistência quanto à oitiva das testemunhas policiais militares. Ao final foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, foram realizados os debates, tendo o Ministério Público requerido a condenação do réu nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Quanto à dosimetria da pena, pediu a fixação da pena-base acima de seu mínimo legal, bem como o reconhecimento das circunstâncias agravantes relativas à calamidade pública e à reincidência. Requereu o reconhecimento das causas de aumento de pena quanto ao emprego de arma e ao concurso de pessoas e, ao final, pediu a fixação do regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu, por falta de provas. Quanto à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base em seu mínimo legal, bem como o afastamento da circunstância agravante relativa à calamidade pública. Pediu, outrossim, a consideração apenas de uma majorante no agravamento da pena, conforme previsão do artigo 68 do Código Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, bem como pela prova oral colhida em Juízo e demais elementos amealhados aos autos.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do crime descrito na denúncia. Disse que foi a uma “biqueira” para comprar drogas e usá-la sob a ponte e, então, deparou-se com indivíduos efetuando um assalto na rodovia. Contou que viu pessoas correndo, mas permaneceu no local, sob a Ponte do Mar Pequeno, para usar entorpecente e, então, foi abordado pelos policiais. Não soube dizer por que motivo foi reconhecido pela vítima e testemunha como um dos autores do crime.

Entretanto, a negativa e a versão apresentada pelo acusado, além de não serem críveis, estão isoladas no conjunto probatório amealhado.

A vítima, ouvida sob o crivo do contraditório, confirmou ter sido roubada quando estava trabalhando como motorista pelo aplicativo “99”, com dois passageiros em seu veículo. Declarou que, na descida da Ponte do Mar Pequeno, os veículos à sua frente pararam. Disse que estava chuvizando na data dos fatos e, ao prestar atenção ao que estava ocorrendo, viu que o primeiro veículo parado à sua frente havia sido abordado por indivíduos que praticaram um roubo e que tais meliantes aproximavam-se na direção de seu carro, que era o quarto veículo parado. Relatou que tentou dar a marcha à ré, porém já havia outros carros atrás do seu, o que impossibilitou sua saída do local, e, então, os meliantes abordaram seu veículo, batendo com armas no para-brisa. Disse que o vidro de sua janela estava fechado e não queria abri-lo, porém o vidro do para-brisa começou a trincar em razão dos golpes com as armas e, então, percebeu que os armamentos eram verdadeiros. Declarou que um dos roubadores que o abordou também lhe disse que a arma não era de brinquedo e, caso não abrisse o vidro, iria efetuar disparo. Narrou que estava sozinho no banco dianteiro do veículo e os dois passageiros estavam no banco traseiro e estes ocultaram os próprios celulares sob o banco do passageiro. Disse que, de sua propriedade, foram subtraídos o aparelho celular, um carregador portátil e objetos que estavam dentro do porta-luvas do veículo. Relatou que o meliante, que posteriormente reconheceu, empunhou a arma na direção de seu rosto e lhe disse que se não tivesse aberto o vidro do veículo, ele teria efetuado um disparo em seu rosto. Disse que desligou seu veículo e falou aos roubadores que eles poderiam levá-lo, porém eles lhe disseram que queriam apenas os outros bens e dinheiro. Declarou que, embora estivesse com dinheiro, os roubadores não o encontraram e disse a eles que nada tinha. Relatou que, então, os meliantes que o abordaram e os demais indivíduos que estavam praticando os crimes dirigiram-se ao veículo atrás do seu. Esclareceu que, logo após o roubo, um de seus passageiros acionou a polícia, comunicando os fatos. Relatou que, após o roubo, saiu do local e dirigiu-se à delegacia. Narrou que,

enquanto aguardava o atendimento na delegacia, dois policiais lá chegaram com um indivíduo, que reconheceu, prontamente, por seu rosto, como um dos meliantes que o roubou. Declarou que, também na delegacia, realizou o reconhecimento formal do roubador, entre outros dois indivíduos, novamente reconhecendo-o. Consignou que o indivíduo que reconheceu como um dos autores do roubo era moreno, media menos de 1,60 metros, magro, usava o cabelo curto e estava um pouco sujo e afirmou que não teve dúvidas quando o identificou em solo policial como um dos autores do delito. Disse, ainda, que, no momento do crime, este indivíduo vestia uma bermuda e uma camisa de manga de cor escura, mas, ao chegar na delegacia, além dessa vestimenta, ela estava usando também um casaco. Consignou que somente estava chuviscando na data dos fatos e os faróis dos veículos estavam acesos, possibilitando ver o rosto dos meliantes. Declarou que seus bens não foram recuperados. Soube pelos policiais que ele foi detido em um canal. Esclareceu que, no local dos fatos, sete a oito indivíduos estavam praticando o "arrastão", tendo visto dois desses indivíduos portando armas, sendo estes os que bateram no para-brisa de seu veículo. Relatou que dois indivíduos que abordaram seu veículo estavam armados, esclarecendo que o roubador que aproximou-se de seu vidro portava arma, mas o que abordou os passageiros não estava armado. Reconheceu o acusado em Juízo, dizendo ter certeza de ser ele um dos autores do crime.

A testemunha Sergio Rodolpho Estrada Junior, ouvida em Juízo, relatou que estava no veículo da vítima como passageiro em viagem pelo aplicativo "99" e, ao descer a ponte para acesso ao bairro Parque Bitarú, mais de oito indivíduos, que haviam bloqueado a via com um colchão, começaram a efetuar roubos. Declarou que a vítima tentou sair do local, mas não conseguiu. Relatou que todos os meliantes estavam armados e abriam as portas dos veículos parados para subtrair pertences e abordaram também o veículo em que estava. Disse que jogou seu celular e sua carteira embaixo do banco, porém a vítima teve seu celular e máquina de cartão subtraídos. Narrou que, quando conseguiram sair do local, acionou a polícia através de seu telefone e, então, foram à delegacia para realizar o registro do boletim de ocorrência. Disse que quando aguardavam, uma viatura policial lá chegou conduzindo um indivíduo que, mesmo antes de tomar ciência sobre o local onde ele havia sido detido, prontamente o reconheceu como sendo um dos roubadores que abordou o veículo em que estava. Consignou que estava sentado atrás do banco da vítima, motorista, e o indivíduo detido foi o que aproximou-se do veículo por esse lado, tendo visto seu rosto no momento da ação criminosa. Esclareceu que o roubador que reconheceu estava acompanhado de outro meliante, cujas características eram pele branca e orelhas mais abertas. Afirmou que também realizou o reconhecimento formal do indivíduo detido, que foi colocado entre outras duas pessoas, reconhecendo-o sem dúvidas como um dos autores do crime. Relatou que o indivíduo que reconheceu em solo policial portava arma no momento do crime e consignou que todos os demais meliantes que estavam no local dos fatos portavam armas, do tipo pistolas, tendo sido o crime praticado com muita violência, pois os meliantes deram coronhadas no para-brisa, trincando o vidro. Soube por um dos policiais que o indivíduo que reconheceu havia sido detido no local dos fatos, sob a ponte, dentro da água. Disse que o meliante que reconheceu na delegacia tinha a pele morena escura e cabelo crespo, além de trajar roupa de cor escura. Reconheceu o acusado em Juízo, sem dúvidas, como sendo um dos autores do crime.

Em face de toda a prova carreada aos autos, diante do relato da vítima e da testemunha presencial, os quais foram fornecidos com segurança e detalhes, não há dúvidas em se concluir que o réu efetivamente participou do delito de roubo descrito na denúncia.

Os depoimentos da vítima e da testemunha presencial são coerentes e harmônicos entre si, estando em verdadeira consonância com suas declarações prestadas na fase extrajudicial.

Assim, em relação ao depoimento da vítima em casos como o dos presentes autos,

destacam-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

“A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si” (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250)

“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM-SP-AC-Rel. Celso Limongi-JUTACRIM 94/341).

Ressalte-se que a vítima e a testemunha presencial Sergio afirmaram terem realizado o reconhecimento do acusado na data dos fatos, não tendo qualquer dúvida de que o réu, que foi o indivíduo detido pelos policiais, foi aquele que praticou o crime.

Veja-se que tanto a vítima quanto a testemunha Sergio afirmaram que, enquanto aguardavam o atendimento na delegacia, policiais lá chegaram conduzindo um indivíduo que ambas, prontamente, identificaram como sendo um dos roubadores.

Acrescentou a testemunha Sérgio que essa identificação ocorreu mesmo antes de ter tomado ciência do local onde aquele indivíduo conduzido pelos policiais havia sido por eles detido.

Ressalte-se, neste ponto, que, embora não tenham sido ouvidas em Juízo as testemunhas policiais militares que realizaram a prisão do acusado, a testemunha Sérgio consignou ter sabido por um dos policiais que conduziram o réu à delegacia que ele foi detido no local dos fatos, sob a ponte, o que confirma os elementos coligidos aos autos na fase inquisitiva.

Outrossim, a vítima e a testemunha esclareceram que, também naquela mesma data, realizaram o reconhecimento formal do indivíduo detido, identificando-o como um dos executores do delito, dentre outras duas pessoas, afirmando, ainda, que, durante a execução do crime, puderam ver seu rosto.

Depreende-se, ainda, das declarações da vítima que o réu foi o indivíduo que apontou a arma para sua face, ameaçando-a, dizendo que teria efetuado um disparo contra seu rosto caso ela não tivesse aberto o vidro do automóvel, e consignou que ele trajava bermuda e camiseta no momento do crime, mesma vestimenta que ainda trajava na delegacia, acrescida de um casaco.

Finalmente, a vítima e a testemunha Sérgio reconheceram o acusado em Juízo, sem qualquer dúvida.

É insubsistente a alegação de que a diligência quanto ao reconhecimento em Juízo tenha sido realizada ao arrepio da lei processual, uma vez que foram observados os termos do disposto pelo artigo 226 do Código de Processo Penal.

O acusado e os outros dois homens, cujas características assemelhavam-se às dele, foram apresentados à vítima e à testemunha presencial e ambas demonstraram ampla certeza no reconhecimento, indicando o réu como um dos autores dos fatos, após realizarem a descrição de suas características físicas.

Frise-se que a Defesa não se insurgiu quanto à forma de reconhecimento ou quanto às pessoas apresentadas juntamente com o réu no momento oportuno.

De mais a mais, o reconhecimento em Juízo, nas lições de Guilherme de Souza Nucci (in Código de Processo Penal Comentado, ed. Forense, 14ª ed, Rio de Janeiro, 2015) trata-se de “reconhecimento informal, que configura um mero desdobramento do depoimento ou das declarações prestadas. Se o juiz preterir as formalidades exigidas neste artigo para empreender o reconhecimento – o que se faz cotidianamente em muitos fóruns – estaremos diante de prova testemunhal.”

Dessa forma, não resta qualquer dúvida sobre a conduta do réu que, mediante grave ameaça contra a vítima, participou do delito de roubo.

O roubo efetivamente se consumou, uma vez que o réu conseguiu apoderar-se da res, que sequer foi recuperada.

Outrossim, depreende-se do conjunto probatório amealhado aos autos, que as causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas restaram comprovadas.

A vítima e a testemunha presencial Sérgio afirmaram que, no local dos fatos, praticando roubos contra todos os veículos que estavam parados, havia, ao menos, sete meliantes, e esclareceram que dois desses indivíduos abordaram o veículo em que estavam, sendo um deles o acusado. Outrossim, bem descreveram a conduta do réu e seu comparsa que, em conjunto, praticaram o crime de roubo.

Da mesma forma, a vítima e a testemunha presencial Sérgio ressaltaram a utilização de arma de fogo pelo réu durante a ação criminosa, tendo a vítima salientado, ainda, que o armamento foi apontado pelo réu na direção de sua face.

Finalmente, a ausência de apreensão da arma usada no crime não afasta a majorante. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do extinto Tribunal de Alçada Criminal – TACrimSP:

“ROUBO QUALIFICADO - Ausência de apreensão da arma - Irrelevância. O fato de não ser apreendida a arma usada no crime de roubo não afasta a qualificadora, se o demonstrar a prova oral produzida na instrução da causa.” (TACrimSP - Ap. nº 913.181/4 - Birigui - 16ª Câ. - Rel. Juiz Eduardo Pereira - J. 23.02.95 - v.u.).

“Em sede de roubo, o desaparecimento do revólver não arreda a qualificadora do emprego de arma, se não desponta dúvida razoável de que um dos co-agentes o empregou” (TACRIM-SP-AC-Rel. Sérgio Pitombo - RJD 19/159).

No mesmo sentido:

“A segura imputação de vítima de roubo, cuja idoneidade não foi abalada, presta-se também a comprovar a circunstância do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal, sem embargo de falta de apreensão de arma” (JTJ 179/276).

“Pouco importa à caracterização do roubo qualificado pelo emprego de arma não ter sido o revólver apreendido e não ter ficado provado o seu poder vulnerante” (RT 741/610-1).

Já decidi nesta Corte:

“ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma de fogo - Ausência de apreensão do artefato utilizado pelo agente - Irrelevância - Qualificadora evidenciada pela comprovação da utilização de arma para a perpetração do delito, em face da prova oral colhida e não impugnada (TJSP)” (RT 878/600).

"ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma - Não apreensão do artefato utilizado pelo agente - Irrelevância - Prova suprida pelo depoimento da vítima - Qualificadora que leva em conta a intimidação sofrida pela vítima e não o poderio do armamento utilizado (TJSP)"(RT 872/636)

"ROUBO QUALIFICADO. Concurso de agentes. Emprego de arma. Sentença condenatória. Insurgência. Afastamento da qualificadora do emprego de arma. Inadmissibilidade. Hipótese em que a não apreensão da arma empregada pelo agente na prática do roubo, não impede o reconhecimento da qualificadora, máxime se confirmada pela vítima e testemunha presencial. Recurso não provido" (Apelação Criminal n. 993.08.019984-1 São Paulo 5ª Câmara de Direito Criminal Relator: Marcos Zanuzzi 26.06.08 V.U. Voto nº 16.272)

Assim, diante da prova produzida, conclui-se com tranquilidade a subsunção dos fatos narrados ao artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, devendo prosperar, portanto, a ação penal.

Firmadas autoria e materialidade dos delitos, passo à dosagem da pena, atentando-me para o critério previsto no artigo 68 do Código Penal.

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, ao se analisar a culpabilidade (conjunto de todos os demais fatores, consubstanciando-se em verdadeiro critério genérico para limitar e fundamentar a pena - cf. NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena, 3ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009, pp. 170-174), verifica-se que o réu agiu com intensa agressividade e frieza, pois, tendo sido bloqueada a passagem de veículos na faixa de rolamento, em companhia de pelo menos mais seis indivíduos, aproximou-se do automóvel da vítima com um comparsa, golpeando o para-brisa com a arma de fogo para obrigá-la a abrir a janela do automóvel, em seguida ameaçando-a, apontando a arma para sua face e dizendo que teria efetuado contra ela um disparo, caso não tivesse aberto o vidro, demonstrando pouco caso com a vida e a saúde da vítima, detentor, portanto, de personalidade transviada. Por todas essas várias razões, aumenta-se a pena-base do acusado em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Considerando a situação econômica de cada réu, estabeleço o valor de cada dia-multa no mínimo legal, devendo ser corrigido desde a data dos fatos.

Na segunda fase da aplicação da pena, observo que o réu é reincidente pela prática de mesma espécie de crime, conforme certidão de fls. 26. Imponho, portanto, um aumento de 1/3 em sua pena, a qual resta fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor já fixado.

Sobre o aumento:

"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/3 NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A reprimenda imposta ao paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador, sendo a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da natureza, quantidade e variedade das drogas. Precedentes. 3. Possibilidade de agravamento da pena em 1/3, na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência específica. 4. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HABEAS CORPUS HC 305029 SP 2014/0244748-0 (STJ). 5ª T. Rel. Min.

GURGEL DE FARIA. Julg. 25/11/2014. Public. 03/12/2014 - grifei)

Verifico, ainda, que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, devendo a pena ser aumentada em 1/6, sendo fixada em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Na última fase do cálculo da pena, verifico que o roubo foi praticado com a majorante do concurso de duas ou mais pessoas, devendo ser a pena acrescida de 1/3. Dessa forma, efetuando-se o acréscimo mencionado, fica a pena fixada em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Ainda, o crime foi praticado com a majorante descrita no §2º-A, inciso I, do artigo 157, em razão de ter sido a ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. A pena deve ser acrescida de 2/3, ficando fixada em 16 (dezesesseis) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor já estabelecido.

Ressalte-se que inexistente ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade, ofensibilidade e razoabilidade decorrente do reconhecimento das duas majorantes do crime de roubo, uma vez que a conduta descrita no artigo 157, § 2º-A, do Código Penal é extremamente grave, o que levou o Legislador a decidir incrementar a pena diante da necessidade de enérgica reprovação e repressão.

Sendo assim, para garantia do princípio da separação dos poderes, não cabe ao Poder Judiciário interferir nas escolhas feitas pelo Poder Legislativo a respeito da apenação mais severa daqueles que praticam determinados crimes, em determinadas circunstâncias.

Nesse sentido, em caso análogo, já se decidiu:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 273, § 1º-B, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OPÇÃO POLÍTICO-LEGISLATIVA PARA APENAR DETERMINADOS DELITOS COM MAIOR SEVERIDADE. INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA INTERFERIR NAS ESCOLHAS FEITAS PELO PODER LEGISLATIVO. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 2. O Poder Judiciário não detém competência para interferir nas opções feitas pelo Poder Legislativo a respeito da apenação mais severa daqueles que praticam determinados crimes, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: "PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 273, § 1º e § 1º-B, INCISOS V e VI DO CÓDIGO PENAL. TRANSNACIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO

DEMONSTRADO. RECONHECIDO CONCURSO FORMAL." 4. Agravo regimental DESPROVIDO." (RE 829226 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 05-03-2015 PUBLIC 06-03-2015)

Outrossim, o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal não traz a exigência de aplicação pelo Magistrado de uma única causa de aumento de pena quando houver concurso de majorantes. Trata-se de uma faculdade, que deve ser justificada, como o foi neste caso concreto.

Neste sentido:

"Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, "D" E "I". ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, "A") E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE "FOTOGRAFAR" MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. A conduta consubstanciada em "fotografar" cenas com pornografia envolvendo crianças e adolescentes amolda-se ao tipo legal previsto no art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), com redação dada pela Lei nº 10.764/2003, notadamente à expressão "produzir fotografia", cujo valor semântico denota o comportamento de "dar origem ao registro fotográfico de alguma cena". 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 241 do ECA, em razão de ter fotografado sua enteada de seis anos de idade em cenas de sexo explícito. Tipicidade da conduta devidamente caracterizada e apenada. 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Boletim Criminal Comentado-março 2019 (semana 2) 8 Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. 6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas "d" e "i", da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual." (HC 110960, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014)

Veja-se, ainda, especificamente acerca das causas de aumento de pena do crime de roubo após a vigência da Lei nº 13.654/18:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sob as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis.

2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento.

3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019)

“Apelação – Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (fatos que ocorreram após o advento da Lei nº 13.654/18) - Materialidade e autoria demonstradas - Confissão dos réus, que foram presos em flagrante na posse dos bens subtraídos - Depoimentos das vítimas e dos policiais militares que atenderam a ocorrência suficientes para justificar o édito condenatório - Crime impossível não caracterizado - Pretensão à desclassificação para forma tentada do delito - Descabimento - Entendimento da Súmula 582, do C. STJ - Condenação mantida - Dosimetria - Penas-base fixadas no mínimo legal - Agravante da reincidência compensada com atenuante da confissão - Exasperação das penas em 1/3 pelo concurso de pessoas e elevada, novamente, em 2/3, pelo emprego de arma de fogo - Impossibilidade de reconhecimento de crime único - Concurso formal bem aplicado - Regime inicial fechado mantido - Recursos improvidos.”

(TJSP; Apelação Criminal 1502842-89.2018.8.26.0019; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 09/10/2019)

Torno essa pena definitiva na ausência de modificadoras.

Na forma do artigo 33 do Código Penal, em razão do montante de pena aplicado, além da reincidência específica do acusado e observando-se, também a gravidade inerente ao delito e as repercussões deste no meio social, tendo em vista que se trata de roubo praticado em concurso de agentes e com grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma de fogo, que foi mostrada e apontada para a vítima, restou demonstrada, de forma concreta, especial periculosidade do réu, motivo pelo qual fixo o regime inicial fechado como regime inicial do cumprimento de pena.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena diante da quantidade de pena imposta, bem como por ter sido o crime praticado com grave ameaça à pessoa, além da reincidência específica do réu. Também pelos mesmos motivos, é incabível o sursis.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua

especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei)

Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu FABIO BIZINELE FELIPE DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, incidente a correção monetária, por infração ao disposto nos artigos 157, parágrafo 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

Nego ao réu o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando-se a gravidade do crime de roubo, praticado com grave ameaça contra a vítima exercida com o emprego de arma de fogo.

Outrossim, o acusado é reincidente. A reiteração de condutas criminosas evidencia a dificuldade do réu em aceitar a ordem legal estabelecida, pois não hesita em reiterar a prática delitiva, colocando em maior risco a ordem social.

Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição.

Portanto, verifico que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo de rigor manter a prisão preventiva, cumprindo-se, outrossim, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do mesmo diploma legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Ausente demonstração mínima suficiente de prejuízos sofridos pela vítima e não tendo havido pedido para tanto na denúncia, inviabilizando-se o contraditório, deixo de condenar o réu nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do direito de reparação do ofendido a ser perseguido na esfera cível.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 11 de março de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA